

1501665-82.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a habitualidade delitiva e participação em organização criminosa. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. ABSORÇÃO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501665-82.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501665-82.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164996/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 25619592 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2164996 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2164996 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS RAFAEL DE JESUS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu LUCAS RAFAEL DE JESUS SILVA, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 10h50min, na Rua dos Caras, nº 314, apto. 44, Parque de São José, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, o acusado guardava e tinha em depósito para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 08 (oito) porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 163,92g (cento e sessenta e três gramas e noventa e dois centigramas); e b) 02 (dois) tijolos de "maconha", com peso bruto aproximado de 1.238,1g (mil duzentos e trinta e oito gramas e um decigramas); tudo sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 114-128).

Os pedidos de liberdade provisória, instauração de incidente de dependência toxicológica e preliminar de nulidade da prisão em flagrante foram apreciados e indeferidos pela decisão de fls. 147-151

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022. Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns e duas arroladas pela defesa.

Nas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls.14-17), auto de exibição e apreensão (fl. 20-21), auto de constatação preliminar (fl. 19) e laudo de exame químico toxicológico (fls.103-106), laudo pericial dos objetos apreendidos (fls. 107-111) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

O policial militar Tiago Renzis Melo, testemunha comum, relatou em Juízo que receberam um chamado via Copom para atender a uma ocorrência de desinteligência, em área rural de Itu, Bairro Mato Dentro. No local, foram informados pela testemunha Sonia que uma moça bateu na porta de sua casa, bastante agitada, pedindo ajuda. Avistaram a moça em um veículo VW Polo. Indagada, foi identificada como Mariana e explicou que esteve em uma festa rave em Sorocaba, com seu namorado Lucas, sendo que acordou sozinha dentro do veículo dele, não sabendo dizer como chegou ali e nem onde estava o namorado. Realizada buscas no interior o veículo, nada de ilícito foi encontrado. Decidiram diligenciar até a residência de Lucas. Mariana informou para equipe de Itu que o namorado vendia drogas e afirmou que haveria entorpecentes na residência dele. Outros policiais foram até a residência de Lucas e lá foram encontradas drogas e efetuada a prisão de Lucas.

O policial militar Alomar Santos Campanha, testemunha comum, relatou em Juízo que foi acionado por equipe da polícia militar da cidade de Itu, a respeito de uma desinteligência na área rural, envolvendo uma jovem que disse ter ido a uma festa com o namorado Lucas em Sorocaba, mas que não sabia onde ele estava. Foram avisados por ela pra ter cuidado porque ele tinha drogas em casa. Dirigiram-se até o apartamento de Lucas. Ele confirmou que durante a festa, Mariana o deixou sozinho pelo local e saiu com o carro dele, sem informar para onde iria. Foi informado aos policiais de Salto que a namorada havia dito aos policiais de Itu que o réu tinha drogas guardadas em sua casa. Lucas confirmou e autorizou a entrada da equipe. Lucas entregou 8 (oito) porções de maconha aos policiais. Indagado se possuía mais drogas, indicou a guarda-roupas em seu quarto, onde foram localizados 2 (dois) tijolos de maconha, uma balança de precisão e duas folhas de caderno com anotações relativas à venda de drogas.

A testemunha de defesa João Andre da Silva Filho, em Juízo, disse que é genitor do acusado. Ele é usuário de drogas.

O réu, Lucas Rafael de Jesus da Silva, interrogado judicialmente, disse, em resumo, que a droga era dele. Reunia-se com outros usuários, pessoas do seu trabalho, comprava em quantidade maiores. Cobrava uma porcentagem para não ter gasto com o seu consumo. Comprou as drogas por aproximadamente R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e repassaria por R\$ 1500,00 (mil e quinhentos reais). Estava com a namorada na festa em Sorocaba. Haviãam bebido bastante.

Os policiais apresentaram versão firme e coerente e rica em detalhes demonstrando que foram informados pela namorada do réu que ele guardava e tinha em depósito entorpecentes destinados a venda, sendo encontrados em sua residência 08 (oito) porções de "maconha" e 02 (dois) tijolos de "maconha", uma balança de de precisão e duas folhas de caderno com anotações de contabilidade das vendas, tendo o acusado confirmado a prática do tráfico de drogas.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

As circunstâncias da prisão, especialmente a quantidade de entorpecente apreendido, acompanhado de instrumentos comumente utilizados para pesagem das drogas e anotações que indicam a contabilidade do tráfico, denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos, especialmente a confissão, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, sem prova de que integre associação criminosa, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo maior quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é considerável: 2 (dois) tijolos de 1209,59g (mil duzentos e nove gramas e cinquenta e nove centigramas) e 8 (oito) porções de 177,23g (cento e setenta e sete gramas e vinte e três centigramas); o réu é primário (fls. 168-169) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de policiais militares sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau intermediário.

Salientando-se que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a habitualidade delitiva e participação em organização criminosa. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. ABSORÇÃO DA CONDUTA RELATIVA AO ART. 33, § 1º, I PELA DO ART. 33, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. CONDUTA ÚNICA. CAFEÍNA UTILIZADA COMO MEIO DE OBTENÇÃO DA DROGA COMERCIALIZADA (COCAÍNA). APREENSÃO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO AGENTE. ÚNICO FUNDAMENTO DECLINADO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A interposição concomitante de recursos tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo estadual não impede a análise da via de impugnação protocolada posteriormente; pois, de acordo com entendimento desta Corte," o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de agravo regimental, ainda que o Parquet Federal tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que configure preclusão consumativa ou violação ao princípio da unirrecorribilidade "(EDcl no AgRg no REsp n. 1.843.259/R0, relator

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020).

2. Sobre a aplicação do princípio da consunção, esta Corte entende que ele "incide quando for um dos crimes meio necessário ou usual para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente, desde que não ofendidos bens jurídicos distintos. Entre os delitos de tráfico de drogas, de seus insumos ou maquinário, pode ocorrer a consunção quando constatado que sejam os insumos ou maquinários confirmados como meios de obtenção da droga comercializada" (HC n. 598.863/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 16/9/2020).

3. Na hipótese em exame, em que pese às instâncias ordinárias salientarem a existência de duas condutas autônomas, não é o caso, pois o armazenamento da cafeína constitui fato praticado no mesmo contexto do flagrante do paciente que portava os entorpecentes, tendo a Corte de origem destacado que " a cafeína seria utilizada para misturar à cocaína durante seu preparo, a fim de obter maior lucro na comercialização do entorpecente ". Assim sendo, deve ser afastada a incidência do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006, ficando apenas o tipo penal do art. 33, caput, da mesma Lei.

4. Sendo a quantidade e a natureza das drogas apreendidas valoradas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar aplicação da minorante do tráfico dito privilegiado, sendo o único fundamento apontado pela Corte de origem para rechaçar a redutora legal, verifica-se indevido bis in idem. Precedentes.

5. No julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva, e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa.

6. No caso, as instâncias de origem não questionaram, em nenhum momento, a primariedade e os bons antecedentes do sentenciado, tampouco aludiram ser ele integrante de organização criminosa, a não ser por presumirem exclusivamente com base na quantidade das drogas apreendidas, o que não se admite. A dedicação à atividade criminosa foi assentada tão somente na quantidade de material tóxico encontrada no momento da prisão em flagrante.

7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 682.984/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 dar epercução geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento do celular Iphone (fl. 20) pertencente ao réu, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes e presente a atenuante da confissão, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 1/3, obtendo a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LUCAS RAFAEL DE JESUS SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Decreto o perdimento do celular Iphone (fl. 20) pertencente ao réu, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006)

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA